

学生A、B及びCは、次の【事例】における甲の罪責について、後記【会話】のとおり検討している。【会話】中の①から⑤までの（ ）内から適切な語句を選んだ場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】

甲は、乙がVに対して暴行を加えていたところに通り掛かり、乙との間で共謀を遂げた上、乙と一緒にVに対して暴行を加えた。Vは、甲の共謀加担前後にわたる一連の暴行を加えられた際に1個の傷害を負ったが、Vの傷害が、甲の共謀加担前の乙の暴行により生じたのか、甲の共謀加担後の甲又は乙の暴行により生じたのかは、証拠上不明であった。

【会話】

学生A. 私は、共犯は自己の行為と因果関係を有する結果についてのみ責任を負うという見解に立ち、後行者は、共謀加担前の先行者の暴行により生じた傷害結果には因果性を及ぼし得ないと考えます。事例の場合、甲には①（a. 暴行罪・b. 傷害罪）の共同正犯が成立すると考えます。事例とは異なり、Vの傷害が甲の共謀加担後の甲又は乙の暴行により生じたことが証拠上明らかな場合、甲には傷害罪の共同正犯が②（c. 成立する・d. 成立しない）と考えます。

学生B. A君の見解に対しては、甲に対する傷害罪の成立範囲が③（e. 狭く・f. 広く）なり過ぎるとの批判が可能ですね。

学生C. 私は、事例の場合には、同時傷害の特例としての刑法第207条が適用され、甲は、Vの傷害結果について責任を負うと考えます。その理由の一つとして、仮に甲が乙と意思の連絡なく、Vに暴行を加えた場合に比べ、事例における甲が④（g. 不利・h. 有利）に扱われることになるのは不均衡であると考えられることが挙げられます。

学生B. 乙には、甲の共謀加担前後にわたる一連の暴行の際にVに生じた傷害結果についての傷害罪が成立するのであり、傷害結果について責任を負う者が誰もいなくなるわけではないということは、C君の⑤（i. 見解に対する批判・j. 見解の根拠）となり得ますね。

1. ①a ②c ③e ④h ⑤i
2. ①b ②d ③f ④g ⑤j
3. ①a ②c ③f ④g ⑤j
4. ①b ②c ③e ④h ⑤i
5. ①a ②c ③e ④g ⑤j

() には、順に「① a ② c ③ e ④ h ⑤ i」が入り、したがって、正解は肢1となる。

承継的共同正犯の成否について、学説は、肯定説、否定説、中間説に分かれる。肯定説は、1個の犯罪を2つに分解して論ずることは許されないと理解に立って、常に後行者に対し、犯罪全体の共同正犯を認める。否定説は、共犯の因果性を一貫させる立場から、関与以前の先行者の行為や結果については、後行者の行為が因果性を持つことはあり得ないことを理由に承継的共同正犯を一切否定する。中間説は、(ア) 後行者が先行者の行為及び結果を自己の犯罪遂行の手段として積極的に利用した場合に、後行者にも関与前の行為及び結果も含めて共同正犯の成立を認める見解と、

(イ) 先行者の行為が、後行者の関与後も効果を持ち続けており、後行者が先行者と共に違法な結果を実現したといえ、後行者の行為と違法な結果との間に因果関係が存在する場合、後行者も行為全体について責任を負うとする見解に分かれる。承継的共同正犯の成立が否定される場合、207条の適用の可否が問題となるが、207条は共犯類似現象に対処する規定であり、共犯関係があれば当然適用してよいとする肯定説と、207条は誰も傷害の罪責を負わなくなる不都合を回避するための例外規定であり、少なくとも先行行為者が責任を負う場合には、207条を適用し、後行者に責任を負わせなくとも不都合ではないとする否定説が存在する。

①について

学生Aは、共犯は自己の行為と因果関係を有する結果についてのみ責任を負うという見解に立ち、後行者は、共謀加担前の先行者の暴行により生じた傷害結果には因果性を及ぼし得ないと考えていることから、否定説又は中間説の(イ)の見解に立っていると考えられる。そして、否定説及び中間説の(イ)の見解からすれば、Vの傷害結果について、甲の共謀加担前に行われた乙の暴行については甲に責任を問えず、甲の共謀加担後の甲及び乙の暴行のみでVの傷害結果が生じたかは明らかでないのだから、甲に傷害罪の共同正犯の成立を認めることはできないといえる。よって、事例の場合、乙と共にVに対し暴行を加えた甲の行為につき、暴行罪の共同正犯が成立することになる。したがって、①には「a. 暴行罪」が入る。

②について

否定説又は中間説の(イ)の見解に立ったとしても、共謀加担後の暴行により傷害結果が生じたことが証拠上明らかといえる場合には、後行者は傷害罪の実行行為の全てを担当したといえ、傷害罪の共同正犯として責任を負うと考えられる。本問の事例の場合、Vの傷害が甲の共謀加担後の甲又は乙の暴行により生じたことが明らかな場合であり、甲は傷害罪の実行行為の全てを担当したといえる。よって、甲の行為には乙との傷害罪の共同正犯が成立する。したがって、②には「c. 成立する」が入る。

③について

否定説及び中間説の(イ)の見解からすれば、Vの傷害結果について、甲の共謀加担前に行われた乙の暴行について甲に責任を問えず、甲の共謀加担後の甲及び乙の暴行のみでVの傷害結果が生じたかは明らかでないことから、甲に傷害罪の共同正犯の成立を認めることはできない。一方、肯定説からすれば、甲の共謀加担後の甲及び乙の暴行のみからVの傷害結果が生じたか明らかでない場合にも、常に後行者である甲に対し、犯罪全体の共同正犯を認めることができるから、甲には傷害罪の共同正犯が成立する。よって、学生Aの見解に対しては、肯定説の立場から、甲に対する傷害罪の成立範囲が狭くなり過ぎるとの批判が可能である。したがって、③には「e. 狭く」が入る。

④について

学生Cは、同時傷害の特例として、207条が適用されると述べていることから、承継的共同正犯の成立を否定し、207条の適用を肯定する説に立っている。そして、承継的共同正犯の成立を否定し、207条の適用を否定する場合には、甲には乙との暴行罪の共同正犯が成立するに留まることとなる。一方で、仮に甲が乙との意思の連絡なくVに暴行を加えた場合には、甲の行為に傷害罪が成立することとなり、共謀が存在しない方が甲にとって不利な結果となるが、共謀をせずに暴行を加えた場合に比べ、共謀の上で暴行を加えた方が責任が軽くなるとするのは不均衡であるといえる。したがって、④には「h.有利」が入る。

⑤について

学生Bは乙には、甲の共謀加担前後にわたる一連の暴行の際にVに生じた傷害結果についての傷害罪が成立するのであり、傷害結果について責任を負う者がいなくなるわけではないとしていることから、207条の適用を否定する説に立っているといえる。よって、学生Bの発言は、207条の適用を肯定する説に立つ学生Cの見解に対する批判となる。したがって、⑤には「i.見解に対する批判」が入る。